

1502077-69.2019.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 2283796-12.2019 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Andradina, 7693362 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1310/2019 -

DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLIANE DE CASTRO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502077-69.2019.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502077-69.2019.8.26.0024

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 2283796-12.2019 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Andradina, 7693362 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1310/2019 -

DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLIANE DE CASTRO MEDEIROS e outro

O Ministério Público ofereceu denúncia contra CARLIANE DE CASTRO MEDEIROS e THIAGO KENJY PAZETI KUROKAWA imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c 40, III ambos da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 11h40min, na Rodovia Municipal Salvador Loverdi, nº 100, Centro, nesta cidade e comarca de Andradina: a) a ré, qualificada às fls.10, 15/16, 20 e 26/29; e b) o réu, qualificado às fls.70, 98 e 104 dos presentes autos, atuando em concurso e com unidade de desígnios entre si e com terceiros trazia consigo, para fins de tráfico, no interior da Penitenciária de Andradina, uma porção de "maconha", com peso aproximado de 35,64g (cf. Auto de constatação provisório de fls.31/32 e exame químico-toxicológico de fls.62/65), substância esta entorpecente e causadora de

dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2022 em decisão de fls.227/228. Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação em fls. 207/208 e 214.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa de Thiago, por sua vez, requereu a absolvição, com pedidos subsidiários e a d. Defesa de Carliane, pugnou pela absolvição em razão da coação moral irresistível, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e aplicação do redutor do § 4º do art. 33, regime de pena intermediário e direito de apelar em liberdade.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela parcial procedência da acusação, responsabilizando-se a corré Carliane pelo delito imputado na denúncia, com absolvição do acusado Thiago. Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/02, boletim de ocorrência de fls.03/05, termo de depoimento de fls.07/08, termo de interrogatório de fl.10, autos de exibição e apreensão de fls.12/13, imagens de fls.24/25 e 119/122, termo de declarações de fl.70, laudos periciais de fls.175/178), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A testemunha e agente penitenciário Leandro Soares Bezerra, narrou que era operador do body scanner na unidade e viu anormalidade no corpo da Carliane. Verificaram e então a ré entregou a droga. A ré não falou diretamente ao depoente qual seria a destinação da droga.

Vanina Rodrigues Moreno, testemunha e agente penitenciário, confirmou a versão de seu colega, dizendo-se que não se recorda da acusada ter indicado o corréu Thiago como destinatário das drogas.

Interrogado, o réu Thiago disse que não sabia que Carliane estaria ingressando com drogas na unidade.

Interrogada, a ré disse que recebeu ajuda de pessoas desconhecidas quando iniciou as visitas a Thiago, mas depois foi cobrada a levar o entorpecente para dentro da unidade, sendo que recebeu ameaças de que poderiam fazer mal a sua pessoa, sua filha e Thiago. Disseram que ou faria isso ou então teria de prestar favores sexuais a outros detentos, sendo que então optou por ingressar na unidade com o entorpecente. Resolveu então fazer essa "besteira". Questionada, disse que deduz que seria possível passar pelo scanner corporal sem que fosse detectada a droga, já que não seria a primeira pessoa a fazê-lo.

Esta a essência da prova oral, no mais registrada por meio audiovisual, na forma do CPP 405, § 1º, dispensada transcrição detalhada de todo o conteúdo dos depoimentos. Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese a corré Carliane foi presa tentando ingressar na unidade prisional com cerca de 35,64 gramas de maconha, quantidade muito superior ao necessário para mero uso pessoal no interior da unidade. Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017), sendo que a quantidade seria suficiente para até 70 cigarros, sendo absolutamente impossível o consumo de tamanha quantidade pela corré durante a

visita. Também não faria sentido que portasse tamanha quantidade para uso próprio e tentasse com ela ingressar no presídio.

Então, a conduta praticada amolda-se ao verbo trazer consigo contido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo, portanto, formal e materialmente típica.

A vontade livre e conciente, ou seja, o dolo, de trazer consigo substância que a ré sabia se tratar de droga está presente.

Não vislumbra-se a presença de nenhuma causa de exclusão da ilicitude.

Quanto à culpabilidade (terceira fase de constituição do fato como criminoso), certo que não comprovada a suposta coação moral irresistível sofrida pela corré. O relato não encontrou respaldo em nenhum elemento dos autos e não mostra-se convincente, notadamente a se considerar que a própria corré possui condenação anterior por crime da Lei 11.343/06, não se tratando de pessoa inexperiente no meio criminoso.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico, em relação a Carliane, é procedente.

Já no que toca a Thiago, certo que a prova indiciária não foi confirmada em juízo, já que os agentes penitenciários ouvidos não confirmaram o quanto contido na fase de inquérito, de que Carliane teria assumido que levaria a droga para seu amásio à época. O fato de já terem praticado tráfico juntos em momento anterior ou de ser Thiago o detendo que a corré visitaria não são elementos suficientes a indicar sua efetiva concorrência para o crime. Ainda que seja intuitivo natural e até provável que Thiago fosse o destinatário do entorpecente, não se descarta a possibilidade de que Carliane levasse a droga espontaneamente, sem qualquer participação ou conhecimento de Thiago, ou que o fizesse para entrega a outras pessoas.

Anoto, por derradeiro, que a ausência de prova da participação de Thiago não exclui o fato criminoso praticado por Carliane, que certamente ingressava no presídio com o entorpecente para fins de tráfico. Cabe dizer apenas que não existem evidências seguras de que Thiago teria participado previamente e aderido à conduta da ré.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano.

Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo

sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça). Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($1/6$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $1/6$ será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

“2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de $1/8$ (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais”. E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): “A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base”.

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, anoto que Carliane ostenta antecedente criminal por tráfico de

drogas, já que cometeu crime anterior ao fato deste processo, cujo trânsito se deu durante o trâmite deste feito (fls. 264/265). Veja-se, o entendimento do STJ sobre a matéria (HC 171212 / DF - 6ª Turma - DJe 20/08/2015): "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes."

Assim, na primeira fase, cabe a exasperação de sua pena-base.

Ressalto que a pena parte do mínimo legal (5 anos) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 10 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (5 anos) o montante de 1 ano e 3 meses de reclusão, montante equivalente a 1/8 de 10 anos (intervalo de pena estabelecido pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime) e estabeleço a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes causas atenuantes ou agravantes.

As declarações da ré não podem ser valoradas como confissão, pois não assumiu a prática do crime, já que disse ter sido coagida a tentar ingressar na unidade com a droga. Ainda que se considerasse tais declarações como confissão qualificada, certo que o conteúdo de seu interrogatório mostrou-se absolutamente desnecessário para a formação do juízo a respeito do fato praticado, já que a ré foi flagrada com entorpecente em seu corpo, o que foi confirmado pelos elementos de prova anteriores a seu interrogatório. Confira-se a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 733879 / SP - 5ª Turma - julgado em 24/05/2022): "Nos moldes da jurisprudência desta Corte, se a condenação foi baseada na declaração da vítima e nos depoimentos das testemunhas, sendo explicitado pelo magistrado, quanto ao acusado, que sua confissão parcial não foi considerada na sentença, não há que se reconhecer a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo, por consectário, descabido o pleito de compensação com a agravante da reincidência na etapa intermediária do procedimento dosimétrico".

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, já que a ré ostenta antecedente criminal por tráfico de drogas praticado 5 meses antes do fato aqui analisado (fls. 264/265).

Cabe aumento em 1/6, em razão do local do cometimento do crime, unidade prisional, na forma do art. 40, III, da Lei 11.343/06. Com isso, a pena vai a 7 anos, 3 meses e 15 dias e pagamento de 729 dias-multa, a qual torno definitiva.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime (ingresso de drogas em

unidade prisional), quantidade de pena e antecedentes deve ser o fechado. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena, sendo que cabe aplicação da lógica do CP 44, § 3º.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação para CONDENAR CARLIANE DE CASTRO MEDEIROS, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c 40, III ambos da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, calculados em seu mínimo legal e ABSOLVER THIAGO KENJY PAZETI KUROKAWA, na forma do CPP 386, VII.

Ausentes fatos contemporâneos a demandar a prisão, recurso em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs. Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas. Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 26 de agosto de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)